

1500250-42.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... dos réus nos graves delitos de tráfico de drogas/associação ao tráfico.

Nesse sentido decisão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico de Drogas - Preliminar de nulidade do mandado de busca e apreensão - Inocorrência - Mandado expedido com base diversas denúncias anônimas que desdobraram em prisão, sendo antecedido, ainda de relatório de investigação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500250-42.2022.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500250-42.2022.8.26.0598 - Controle 2022/001295

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS AMERICO DE OLIVEIRA e outros

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2151395/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 25362368 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2151395 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Juiz de Direito: Dr. PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

LUÃ BATISTA PRIMO e FÁBIO RODRIGO PEREIRA foram denunciados pelo Ministério Público, como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material (CP, art. 69), enquanto MARCOS AMÉRICO DE OLIVEIRA como incurso no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em período incerto, até o dia 03/06/2022, agindo em concurso e com unidade de propósitos, associaram-se, de maneira estável e duradoura, para praticar, de forma reiterada, o tráfico ilícito de drogas nesta cidade (item 1 da denúncia); então, no dia 03/06/2022, por volta das 6h, em cumprimento a um mandado judicial de busca e apreensão (fls. 1), Policiais Civis dirigiram-se até os imóveis situados na Rua Aristides Souza Ferraz, nº 430 (residência de Fábio), Rua Tancredo Costa, nº 51 (residência de Luã) e na Rua Júlio Vono, nº 190 (casa da mãe de Luã), todos no Jardim Jorge Atalla, nesta cidade, ocasião em que localizaram, para fins de tráfico, 2.934g de cocaína e 269,54g de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar (item 2 da denúncia).

Regularmente notificados (fls. 405, 411 e 412), os réus ofereceram respostas escritas à acusação (fls. 419/435 [Luã], 438/439 [Fábio] e 444/445 [Marcos]), sendo a denúncia recebida em 13/09/2022 (fls. 460/463).

Em instrução, ouviram-se testemunhas, interrogando-se os réus ao final (fls. 520/521 e 562/564).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou pela procedência da ação penal, com a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 565/568).

A Defesa de Luã, em essência, pugnou pela absolvição integral e, subsidiariamente, requereu a desclassificação da imputação de tráfico para o crime de posse de droga para uso próprio ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, fixando-se o regime aberto e o substituindo por penas restritivas de direitos (fls. 569/576).

A Defesa de Fábio e Marcos pugnou, em linhas gerais, pela nulidade da busca e apreensão em decorrência da inobservância dos requisitos legais, pois baseada em informações anônimas. Prosseguindo, invocando a ausência de provas, inclusive quanto à existência de vínculo para o crime de associação, propugnou pela absolvição (CPP, art. 386, VII) e, ainda, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, pediu a aplicação da pena mínima, regime mais brando e recurso em liberdade (fls. 577/589).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, não há que se falar em ilicitude da prova material, haja vista que a decisão que deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão nos imóveis relacionados aos réus foi proferida após a análise do relatório (que inclusive estava ilustrados com fotos dos locais) apresentado pela Delegacia Especializada da Polícia Civil (DISE). Assim, o deferimento da busca domiciliar não se deu de forma leviana, pelo contrário, pois se baseou em sérios indícios apurados pela Polícia Civil, após o recebimento de denúncia anônima, apontando o envolvimento dos réus nos graves delitos de tráfico de drogas/associação ao tráfico.

Nesse sentido decisão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico de Drogas - Preliminar de nulidade do mandado de busca e apreensão - Inocorrência - Mandado expedido com base diversas denúncias anônimas que desdobraram em prisão, sendo antecedido, ainda de relatório de investigação elaborado pela Polícia Civil - [...] - Preliminares rejeitadas [...]. (TJSP - Apelação Criminal 1504083-

94.2021.8.26.0536; Relator: André Carvalho e Silva de Almeida; 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2022 - destaquei).

Acresça-se, ainda, que a informação anônima foi recebida por agente público cujo ato sabidamente goza da presunção de legitimidade e veracidade decorrente do exercício do cargo que ocupa e, ressalte-se, que não foi em nenhum momento infirmada. Ademais, a Investigação policial originada por informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redundam em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. (STJ - AgRg no HC n. 729.670/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Anote-se, ainda, que havendo indícios suficientes da ocorrência de ilícito, o Magistrado tem o poder-dever de determinar a realização de diligências para apuração dos fatos e, dentre as diversas medidas excepcionais, está a expedição de mandado de busca e apreensão.

Aliás, lembre-se de que o tratado tráfico de drogas, crime não só grave, como equiparado a hediondo com esteio constitucional (CF, art. 5º, XLIII), e que fomenta toda uma rede criminalidade, é considerado delito permanente.

Portanto, como o deferimento da busca e apreensão obedeceu aos requisitos legais, não há qualquer nulidade a ser decretada.

Prosseguindo, a presente ação penal é parcialmente procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 26/27) e de constatação provisória de substâncias ilícitas (fls. 28), e, sobretudo, pelo laudo

de exame químico-toxicológico (fls. 253/263 [cocaína e maconha]) e do relatório de extração de dados dos telefones celulares (fls. 38/43).

Autoria e elemento subjetivo inequívocos.

O Policial Civil Balduin falou que foi até a residência de Fábio, e outras equipes foram na casa de Luã e na casa da mãe dele. Na casa de Fábio, ele falou que no guarda-roupa havia droga, e encontraram cocaína. A informação era de que Fábio guardava droga para Luã e Marcos. No porta-malas do veículo havia mais droga, segundo o próprio réu, onde localizaram mais entorpecente. Sobre maconha, ele falou que havia cerca de 5 a 6 kg no dia e a genitora, ao ter conhecimento da droga, fez com que ele a retirasse do local. A droga, segundo apurado, seria pertencente a Luã. No local, Fábio falou que guardaria a cocaína para Marcos, e a maconha, além de parte da cocaína, para Luã. Na casa de Luã foi encontrado um cigarro de maconha e duas porções da mesma droga, que ele falou que era da mulher dele; a mulher dele falou que só o cigarro era dela, enquanto ela negou a propriedade das porções. Em frente à casa da genitora de Luã, foram encontradas várias porções de cocaína. Não há outro traficante naquele perímetro, a não ser ele que age naquele trecho. No telefone de Luã, havia informação de que ele estava no tráfico, pois ele falara 1 ou 2 dias antes da prisão que ele havia recebido uma quantidade de drogas, maconha e cocaína. Luã falou que iria fracionar a droga na casa dele com "Topeira", e que depois iria passar na casa da mãe dele guarda um "negócio" (no que se entende por droga). No telefone de Fábio, há uma conversa em que fala de levar droga para uma pessoa de "Mateus" ou "Luquinha", de Brotas, e ele se reporta a Luã o que ele deveria fazer. Fábio guardava droga para Marcos e Luã, mas acredita que Luã e Marcos não tinham contrato entre eles. Só identificou uma conversa entre Marcos e Fábio, em que aquele pede drogas para este.

A testemunha Policial Civil Guilherme disse que iniciaram investigação porque havia informações de que Fábio guardaria drogas para Luã e Marcos. No dia da busca, no terreno em frente à casa da genitora de Luã, encontrou porções de cocaína e maconha. Nas diligências, teriam sido encontradas, por outros policiais, 04 porções de cocaína na casa de Fábio, no guarda-roupa e no veículo, e ele teria falado que a droga seria de Marcos. Também inferiram mensagens de celular em que havia conversas envolvendo drogas. Não haveria vínculo, porém, entre Marcos e Luã. Não se recorda se havia o telefone de Luã cadastrado em algum dos telefones apreendidos.

A testemunha Larissa, esposa do réu Luã, mencionou que a polícia ingressou em sua residência e acharam "um baseado" e duas porções de maconha, que são para uso. Não sabe se Luã e Fábio têm relação de amizade. Sobre as conversas de fls. 38/40, refere-se a uso de droga, e não comercialização.

A testemunha Policial Civil Filipe falou que fez o cumprimento de mandado na casa de "Fabio", conhecido como "Capeta". Lá localizaram ele e a mãe dele. Nas buscas, Fábio indicou, em seu guarda-roupa, uma porção de cocaína, e negou a existência de outra droga. Num segundo momento, novamente indagado, ele informou que havia mais droga no veículo que havia na garagem. No aparelho celular foram localizadas conversas relacionadas a ele e Luã. Na casa de Luã, outra equipe encontrou cigarros de maconha e, no terreno na frente ao imóvel, porções da mesma droga, pelo que se recorda. A informação é de que Fábio guardaria a droga para Luã.

Em seu interrogatório, Fábio falou que reside com sua genitora e comprou a droga localizada pela polícia. Comprou a droga sem sua mãe saber, e foi ela que o denunciou. Comprou a droga para uso e para venda. Vendia entorpecente desde 2020, em razão da ausência de trabalho a partir do início da pandemia. Conhece os corréus, mas "da rua", não tendo amizade com eles. Não chegou a vender droga para Marcos; apenas deu droga para ele, sem cobrar, pois o conhece do bairro.

Interrogado em juízo, Luã negou envolvimento nos crimes. Aduziu que a polícia entrou na casa procurando entorpecente. Falou a eles que havia apenas duas porções de maconha, uma na geladeira, e uma no armário, ambas para uso próprio. Sobre a conversa de fls. 38 e ss. com sua esposa, apenas pediu a ela para dividir o entorpecente para usar (10g de cocaína e 50g de maconha). Conhece Marcos porque são vizinhos; não é amigo dele nem de Fábio, mas apenas os conhece.

Marcos negou qualquer envolvimento nos fatos. Falou que conhece os corréus, mas não mantém amizade com eles. Já pediu droga para Fábio, mas não conseguiu porque ele

não tinha. Sabe que ele consumia entorpecente, e por isso pediu a ele; não sabe se ele é traficante.

Pois bem.

Como se vê, encerra-se um contexto probatório inabalável no sentido de que, ao menos, os réus Luã e Fábio estavam associados e operavam o tráfico de drogas, pois as versões apresentadas por eles permaneceram isoladas nos autos (CPP, art. 156, caput), notadamente, diante dos coesos, detalhados e uníssonos depoimentos dos Policiais Civis da Delegacia Especializada (DISE).

Ressalte-se, ademais, que nenhuma razão existe para se duvidar da versão dos Policiais Civis que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado a respeito na nota de rodapé, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020). Até porque, como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. No caso, não haveria, nem foi apontada, razão plausível para que incriminassem o réu injustamente (Apelação Crime Nº 70045139300, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 21/03/2012 - destaquei).

Além disso, porque a quantidade e variedade das drogas apreendidas com os integrantes (Luã e Fábio) da associação (2 porções de maconha [4,28g na residência de Luã], 5 porções da mesma droga [220,77g], além de 27 invólucros de cocaína [92,07g - tudo localizado no terreno defronte à casa da mãe de Luã - utilizado por este para esconder a droga] e 4 porções grandes de cocaína [2699,15g com Fábio - fotos de fls. 87]), os locais das diligências (imóveis ligados a Luã e Fábio), convergem também, sem qualquer espaço para dúvida, à conclusão de que eles estavam associados e, então de forma estável entre si, praticando a traficância.

Ademais, segundo o Policial Civil Balduin, Fábio afirmou informalmente, ainda no calor dos acontecimentos, que guardava drogas para Luã, o que convergem também, sem qualquer espaço para dúvida, à conclusão de que eles estavam associados e praticavam a traficância.

Acrescente-se, ainda, que a fala judicial da testemunha Larissa - companheira do réu Luã - em nada altera o fato aqui tratado, inclusive porque os dizeres dela - de que a droga encontrada em sua casa era para uso - não encontrou apoio nas demais provas existentes nos autos e foi divergente da versão dela apresentada na fase policial, pois, logo após a apreensão das drogas, afirmou que apenas "o baseado era dela para o seu consumo", nada mencionando sobre as outras porções de maconha. Ademais, tentando desvincular a união entre seu companheiro Luã e o corréu Fábio, disse desconhecer a relação de amizade entre eles. Contudo, na fase policial, de maneira diversa da apresentada em juízo, afirmou que eles (Luã e Fábio) se encontravam aos finais de semana, além de Fábio já ter ido em sua casa realizar um serviço (fls. 15 - Fábio, vulgo Capeta, o qual é seu vizinho do bairro, chegando a frequentar a casa deles para cortar uma árvore e por frequentarem o bar do Zé Ribeiro, onde ficam jogando e bebendo nos finais de semana). Assim, a fala judicial dela deve ser analisada com ressalva, pois diferente daquela apresentada logo após os fatos aqui tratados.

Lembre-se de que o E. Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que são admissíveis, para fundamentar a condenação, os elementos informativos produzidos no inquérito policial, desde que sejam confirmados por provas obtidas durante a instrução criminal. [...]. (STJ - AgRg no AREsp: 78829 SP 2011/0267024-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015). Provas essas (sob o contraditório) que, neste caso, constata-se dos firmes e coesos depoimentos dos Policiais Civis e, frise-se novamente, sem qualquer indicativo de falsa inculpação, bem como dos demais elementos de convicção reproduzidos em Juízo, como os que se extraem da postura

tendenciosa e das narrativas inconsistências dos relatos dos réus.

Ressalte-se, ainda, que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Há ainda o conteúdo da extração de dados dos telefones celulares apreendidos com os réus Luã e Fábio (fls. 38/43), o que evidencia a associação deles com o tráfico de drogas. Vejamos:

- Telefone celular de Luã

Mensagens entre Luã e Larissa (dias 01 e 02/06/2022)

Áudio 1: O, chegou tudo junto, Fia, chego o verde, chego o branco, ou, eu tenho que dá atenção, eu tenho eu me vira com isso, meu!

Áudio 2: Não é meu, sabe porque, eu to, tava ocupado lá em casa lá, entendeu, não é bom pega ele agora. O Topeira vai chega aqui as 06:30 e nois vai desce em casa lá pra corta, mais é rapidinho, só uma peça do branco que fico comigo e uns do verde, deixa cortado pra depois não mexe, tá, te amo.

Áudio 3: Amor, é que eu passei na sua mãe primeiro, agora parei no Gão e parei aqui na minha mãe, agora e vo lá guardar o negócio. Tá bom, jaja eu to descendo.

(Ao que consta, segundo relatório policial, dos diálogos é possível concluir que Luã avisa Larissa que havia chegado "verde" [maconha] e "branco" [cocaína], bem como, em companhia do indivíduo conhecido por "Topeira", iria fracionar ["cortar"] as substâncias e guardar o "negócio" na casa de sua mãe).

- Telefone celular de Fábio

Mensagens entre ele (Fábio) e Luã (dias 20 e 23/05/2022)

Áudio 01: O teus eu levo eu levo, tá ligado tato? mas é o lance do cara lá, tá ligado mano? Cê entendeu mano? tem na moeda la? Ce entendeu, meu? Certo irmão? Guardei a última peça cara, ninguém tem, cara, certo? Ainda conseguimos, deu um trabaio rapai! Aí irmão, cê ucê fala assim amanhã, eu vo, compro a passagem, mano, e vo pra Brotas leva lá pro Luquinha, tá ligado, mano? Beleza Mateus? Cê entendeu, tato? Ou irmão, o Luã, dá uma atenção pra mim um minuto? , um minuto só. Não, referente, puta merda. Eu também, eu moro...Você mora onde? No Jorge Atala, neh! Eu também moro no Jorge Atala, neh! É o parceiro, que ele tá viajando, tá lá, eee eu vou levar amanhã pra ele, tá, tato? Vo comprar a passagem, pra Brotas.

Luã: Amanhã cedo você manda mensagem pra mim, se ele falar que é isso memo, vai.

Confira ainda esta pontual lição doutrinária: Todavia, nem sempre é possível a prova direta desses fatos específicos, ora porque foram clandestinos, ora porque são subjetivos, ora porque a prova direta pereceu ou é impossível. Nesses casos o labor probatório se desenvolve com prova indireta, cujo objeto são fatos que não estão previstos na lei com geradores de consequências jurídicas, mas que podem levar à conclusão sobre a existência daqueles fatos legalmente relevantes para se alcançar o resultado pretendido. Esses fatos, objeto da chamada prova indireta, são os indícios, que se conceituam como fatos ou circunstâncias de fato que podem levar à conclusão da existência de outros fatos. [...] verifica-se que entre a prova do indício e a convicção da existência do outro fato, o juiz, mentalmente, dá um salto, através de um raciocínio lógico, mediante a aplicação de 'presunções' ou 'regras de experiência'. [...] No primeiro caso, a convicção da existência resulta de imposição legal. No segundo, da aplicação de uma regra que o juiz extraiu da observação técnica ou da observação do que ordinariamente acontece no comportamento humano. [...] As regras de experiência, comum ou técnica, não estão no plano dos fatos e, portanto, do ônus da prova, podendo e devendo o juiz aplicá-las de ofício, como faria com as presunções legais, podendo, contudo, a parte ter interesse em desenvolver atividade argumentativa sobre tais regras, como faria juntando pareceres jurídicos sobre a interpretação do direito, mas nesse caso não se trata, propriamente, de atividade probatória, mas apenas de atividade dialética de argumentação e colaboração. [...] As presunções que decorrem das regras da experiência, quer a técnica, quer a comum, admitem prova em contrário, ou seja, as partes podem pretender demonstrar que certo fato não tem o significado que parece ter ou que ordinariamente teria. Todavia, o ônus de demonstrar essa peculiaridade é

de quem pretende desfazer a conclusão que naturalmente decorreria. [...] (GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p. 208, 209 e 211 e 212).

Acresça-se, ainda, que o tipo penal analisado (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) descreve várias condutas, sendo classificado como misto alternativo, ou seja, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos-tipo para que o delito se configure. Nesse sentido: [...]. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020 - destaquei).

Por outro lado, a simples alegação de os réus seriam (somente) usuários de drogas não tem o condão de eximi-los (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. No mesmo rumo: [...] a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

É então de se assentar, também, que mesmo em casos nos quais as negociações sobre o comércio de drogas tenham sido esporádicas ou menos frequentes, ainda assim a conduta pode se subsumir ao tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/06, pois o realmente relevante é a estabilidade do vínculo associativo, ou seja, um liame para além do meramente ocasional, efêmero e, por isso, um efetivo animus associativo. A propósito, confira a abalizada doutrina: [...] Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a ser concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão "reiteradamente ou não", a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29). [...] (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Penal Especial Comentada: Volume Único - 6. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2018, pg. 1048).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] 3. Considerando a expressão utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. [...] (HC 596.946/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). E mais: [...] A configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Do contrário, o caso é de mero concurso

de pessoas. 3. As instâncias ordinárias embasaram a condenação dos pacientes em elementos fáticos e probatórios concretos - com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais -, os quais, detidamente examinados em primeiro e segundo graus de jurisdição, conduziram à conclusão de que os réus integrariam, de maneira estável e permanente, associação criminosa voltada à comercialização ilícita de entorpecentes. [...] (AgRg no HC 618.503/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Assim, pela conjugação de todos esses elementos de convicção, amparada pelos diálogos localizados nos telefones celulares apreendidos, não há a mínima dúvida de que, ao menos, os réus Luã e Fábio associaram-se, de forma estável e permanente, não estanque ou sob mera coautoria, para a prática do tráfico de drogas, formando uma verdadeira *societas sceleris* para essa finalidade. Não se tratou de uma finalidade destacada somente para a ocorrência tratada, mas sob o evidente ajuste de continuidade/estabilidade. Isso porque, frise-se, toda a prova também demonstrou - com coerência e coesão entre todos os meios por que reproduzida sob o contraditório, robustez e consequente segurança - que não houve um encontro meramente fortuito entre eles em relação às drogas apreendidas, mas sim porque ambos agiam em conjunto.

Descabida a também alegada versão de Fábio em autodefesa de que passou a comercializar drogas em razão da ausência de trabalho (após o início da pandemia), pois, afora a insuficiência de prova nesse sentido (CPP, art. 156, caput, primeira parte), ele tinha alternativa lícita. Sendo certo, então, que a mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos (TJSP - Ap. Crim. nº 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.^a Câm. Crim. j. em 29.07.2011).

Prosseguindo, em relação ao corréu Marcos, denunciado apenas pelo crime de associação ao tráfico, o realmente relevante, para os presentes fins, é que nada há produzido sob o contraditório indicando suficientemente que ele estava associando aos corréus (Luã e Fábio) no tráfico de drogas, até porque, na conversa juntada aos autos (realizada em 27/12/2021), ao que parece, Marcos pede para "Fábio" dez reais de "pedra" ("Então amigo. Quero pegar 10 reais de pedra" [fls. 41]). ÁUDIO: E aí Fábio, como que cê tá meu parceiro? Tá encima na tua casa? Queria vê se tem como você arruma aquela paradinha lá do pó lá pra mim, amigão.

Assim, tudo indica que, ele (Marcos) - durante a saída temporária (v. fls. 459 [saiu do estabelecimento prisional em 23/12 e retornou aos 03/01/2022]) estava querendo adquirir droga de Fábio e não associado a ele com o tráfico. Necessário era, então, que se tivesse demonstrado durante a instrução processual que o réu Marcos efetivamente aderira e atuava ou participava dos atos praticados pelos corréus Luã e Fábio, já que não basta mero conhecimento e/ou convivência com os atos de terceiros para a configuração do crime (conduta - dolo).

Diante disso, não há que se falar na caracterização do delito de associação ao tráfico em relação ao corréu Marcos, pois tal crime não ficou seguramente comprovado pela prova reproduzida em Juízo, conforme acima exposto. Nesse rumo: ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - [...] - Conjunto probatório inapto à manutenção da condenação - Prova acusatória insuficiente à comprovação de ligação estável do recorrente com os demais réus - In dubio pro reo - Decretação da absolvição, nos termos do art. 386, VII, CPP - Recurso provido, com expedição de alvará de soltura. (TJSP - Apelação Criminal 1500310-97.2018.8.26.0228 - Relator: Newton Neves; 16.^a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8.^a Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2021).

Renato Marcão, quanto ao delito de associação ao tráfico, ensina o seguinte: "Não basta, não é suficiente (...) a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes. É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável". É, ainda, "necessário que se identifique, na *societas criminis*, o caráter permanente, que não se confunde com a mera coautoria" (TÓXICOS - Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei de drogas. 9.^a ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 172).

Por isso e neste caso, Marcos deve ser contemplado com o secular princípio da dúvida que rege a causa penal nesta fase processual e, então, ser absolvido a

imputação de associação ao tráfico de drogas.

Afora isso tudo, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-

87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

Por conseguinte, de rigor a condenação somente dos réus Luã e Fábio, passo à dosimetria das penas, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas (aproximadamente 224g de maconha e 2791g de cocaína), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Ademais, devem ser consideradas os maus antecedentes de Luã, conforme FA de fls. 161/173 (com cinco condenações definitivas [fls. 155 - proc. 1104-67.2018 {tráfico - TJ em 05/09/2019}, fls. 157/158 - proc. 15343-23.2011 {furto - TJ aos 14/08/2012}, fls. 158/159 - proc. 3004770-98.2013 {furto - TJ em 24/11/2014 e pena extinta aos 15/09/2017}, fls. 159/160 - proc. 3008745.31.2013 {receptação - TJ em 22/09/2020} e fls. 156 - proc. 213-02.2016 {embriaguez ao volante - TJ aos 23/05/2019}) e de Fábio, consoante FA de fls. 180/189 (com duas condenações definitivas [fls. 175/176 - proc. 251-48.2018 {furto - TJ em 18/07/2017} e fls. 177 - proc. 9609-28.2010 - {roubo - TJ em 17/12/2012 e pena extinta aos 02/07/2018}]). Assim, diante da multiplicidade de reincidências de Luã e Fábio, apenas uma delas será utilizada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da aludida agravante (CP, art. 61, I), enquanto a(s) outra(s) será(ão) considerada(s) nesta primeira fase a título de maus antecedentes. Diante disso, as penas-base reclamam ser exasperadas, resultando para LUÃ em 7 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 714 dias-multa, referente ao delito de tráfico ilícito de drogas, e 4 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 1000 dias-multa referente ao delito de associação para o tráfico; FÁBIO em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa, referente ao delito de tráfico ilícito de drogas, e 3 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 900 dias-multa referente ao delito de associação para o tráfico, mas com os dias-multa calculados sobre o mínimo legal, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réus (CP, art. 60 c/c Lei nº 11.343/06, art. 43).

Na segunda fase, em virtude da confissão de Fábio (CP, art. 65, III, d), mas somente quanto ao crime de tráfico de drogas, aplico o decréscimo de 1/6, pois o mais proporcional ao quanto considerado. Em razão da reincidência (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I) de Fábio (fls. 175/176 - proc. 251-48.2015 [TJ 18/07/2017]) e de Luã (fls. 155 - proc. 1104-67.2018 [TJ em 05/09/2019]), conforme anteriormente destacado, aplico o acréscimo de 1/6, pois o mais proporcional à quantidade e qualidade da agravante reconhecida, mas o compensando com o decréscimo anterior em relação ao crime de tráfico de drogas quanto ao réu Fábio, permanecendo a pena dele no patamar anteriormente fixado (6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa), mas o delito de associação ao tráfico atinge 4 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão e 1050 dias-multa. Quanto ao réu Luã redimensiono as penas para 8 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão e 833 dias-multa, referente ao delito de tráfico ilícito de drogas, e em 4 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão e 1166 dias-multa referente ao delito de associação para o tráfico.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem observadas, tampouco a do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois em evidente incompatibilidade objetivo-subjetiva com o crime autônomo de associação e, ainda, porque os réus (Luã e Fábio) são reincidentes. A propósito: [...]. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reincidência demonstra dedicação do agente à atividade criminosa, justificando a não aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado, uma vez que denota o não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. [...]. (STJ - AgRg no HC 599.704/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020 - destaquesi).

Como os réus Luã e Fábio, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes diferentes, portanto, em concurso material (CP, art. 69, caput), aplicam-se cumulativamente as penas.

Nos termos do art. 33, § 2º, a e § 3º, do Código Penal, os réus Luã e Fábio devem iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (CP, art. 34), sendo certo que qualquer outro regime não seria suficiente à reprovação ou, ainda, à prevenção de outros crimes, além da quantidade da pena ([...]). 4. Diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequada a fixação do regime inicial fechado para início do desconto da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 5. Ordem denegada (STJ - HC 424.098/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018). Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c arts. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, tudo o que foi apreendido neste processo deve ter o perdimento decretado, à exceção da motocicleta (fls. 20 e 26/27) apreendida na casa de Luã (mas em nome de terceira pessoa [fls. 20]), pois não demonstrado com suficiência se era utilizada para o tráfico ou adquirida com o proveito do delito.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de:

a) LUÃ BATISTA PRIMO, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material (CP, art. 69), à pena total de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e de 1999 (mil novecentos e noventa e nove) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo;

b) FÁBIO RODRIGO PEREIRA, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material (CP, art. 69), à pena total de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e de 1692 (mil seiscentos e noventa e dois) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo; e

c) MARCOS AMÉRICO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao réu Marcos, respondendo a este processo em liberdade, reconheço a ele o direito de assim permanecer em caso de recurso.

Deixo de reconhecer aos réus Luã e Fábio o direito de recorrerem em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque responderam presos ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-los em liberdade exatamente depois de receberem a sentença penal condenatória. A propósito, confira: [...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal já afirmou em outras oportunidades que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema. [...] (STJ, RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). Assim, recomende-se eles na prisão e expeça-se guias de recolhimento, encaminhando-as, com as peças obrigatórias, ao Juízo de Execução.

Decreto o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo, à exceção da motocicleta (fls. 20 e 26/27), que deve ser efetivamente liberada ao legítimo proprietário (mediante comprovação por meio de documento) e, caso ausente ou desconhecido, proceda-se na forma do art. 123 do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial. Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que os réus Fábio e Marcos são assistidos pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe. Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 14 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA